E-Business Recht

Laurin Seeholzer

November 8, 2026

Contents

1 Rechtsanwendung im Internet **4**
- 1.1 Grundlagen . . . 4
- 1.2 Ermittlung des anwendbaren Rechts . . . 4
- 1.3 Beispiele . . . 5

2 Schutz fremder und eigener Inhalte **6**
- 2.1 Einführung und Beispiele . . . 6
- 2.2 Das Urheberrecht . . . 6
- 2.3 Verwertungs- und Persönlichkeitsrechte . . . 7
- 2.4 Beschaffung von Rechten und Lizenzierung . . . 7
- 2.5 Haftung von Plattformen und Hosting-Diensten . . . 8
- 2.6 Gesetzliche Schranken und Digital Rights Management . . . 8
- 2.7 KI und Urheberrecht . . . 9
- 2.8 Rechtsfolgen und Schutz ausserhalb des URG . . . 9
- 2.9 Domain-Namen . . . 10
  - 2.9.1 Grundlagen und Aufbau . . . 10
  - 2.9.2 Vergabesystem und Akteure . . . 10
  - 2.9.3 Rechtliche Natur und Vergabe . . . 10
  - 2.9.4 Kennzeichenfunktion und Schutzrechte . . . 11
  - 2.9.5 Rechtsverletzung und Verwechslungsgefahr . . . 11
  - 2.9.6 Sonderkonstellationen und Schranken . . . 11
  - 2.9.7 Streitbeilegung und Schlichtungsverfahren . . . 12

3 Haftung und Rechtsverfolgung im Netz **14**
- 3.1 Ausgangslage und Cyberrisiken . . . 14
- 3.2 Grundvoraussetzungen der Haftung . . . 14
  - 3.2.1 Strafrechtliche Verantwortlichkeit . . . 14
  - 3.2.2 Zivilrechtliche Haftung (Schadenersatz) . . . 15
- 3.3 Haftungsverteilung, Rückgriff und Organverantwortung . . . 15
  - 3.3.1 Haftung im Unternehmen und Regress . . . 15
  - 3.3.2 Verantwortung des Verwaltungsrats und Sorgfaltsmassstab . . . 16
- 3.4 Provider-Haftung und Rechtsdurchsetzung . . . 17
- 3.5 Risiko von Cloud-Providern und ausländischem Behördenzugriff . . . 18

4 Verträge im Netz **20**
- 4.1 Vertragsschluss und Konsensus im E-Commerce . . . 20
- 4.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) . . . 21
- 4.3 Informationspflichten und Konsumentenschutz . . . 22
- 4.4 Beweis, Schriftform und Elektronische Signatur . . . 23

5 Datenschutzrecht (DSG) **24**
- 5.1 Grundbegriffe und Geltungsbereich . . . 24
- 5.2 Bearbeitungsgrundsätze (Art. 6 und 7 DSG) . . . 25
- 5.3 Rollenverteilung und Datenübermittlung . . . 25
- 5.4 Betroffenenrechte und Organisatorisches . . . 26
- 5.5 Sonderfälle und Begleitgesetze . . . 27

6 Verträge mit IT- und Internet-Providern **29**

6.1 Vertragstypen und rechtliche Qualifikation 29
6.2 Wesentliche Vertragsinhalte und Service Level Agreements (SLAs) 29
6.3 Mängelrechte und Gewährleistung im Werkvertrag 30
6.4 Vertragsbeendigung 31

1 Rechtsanwendung im Internet

1.1 Grundlagen

Definition 1.1. DSGVO: Die Datenschutz-Grundverordnung der EU regelt den Umgang und die Verarbeitung von Personen-bezogenen Daten in und ausserhalb der EU.

Remark 1.2. Die DSGVO findet Anwendung, wenn

- Dienstleistungen in der EU angeboten werden
- Das Verhalten von Personen in der EU beobachtet wird (sofern dieses Verhalten in der EU stattfindet)

Theorem 1.3. Jeder **Staat bestimmt selbst**, wo das eigene Recht Anwendung findet.

Definition 1.4. Anknüpfungspunkt: Sachverhalt welchen Rechtsfall mit einem Land/Behörde in Beziehung setzt, respektive eine relevanz legitimiert.

Remark 1.5. Die blosse Abrufbarkeit einer Website in einem Land genügt in der Regel nicht als Anknüpfungspunkt; entscheidend ist meist, ob ein Angebot auf ein Publikum im Land ausgerichtet ist oder dort Auswirkungen hat.

Definition 1.6. Souveränität: Amtshandlungen auf Schweizer Boden sind grundsätzlich den Schweizer Behörden vorbehalten. Ausländische Herausgabebefehle auf z.B. Rechenzentren in der Schweiz können mit dem Schutz der Schweizer Souveränität über Art. 271 StGB (verbotene Handlungen für einen fremden Staat) kollidieren.

1.2 Ermittlung des anwendbaren Rechts

Theorem 1.7. Die Ermittlung des anwendbaren Rechts passiert in Schritten:

- **Örtlich zuständige Behörde ermitteln:**
  Dies können Gerichte in mehreren Staaten gleichzeitig sein.
  Die Schweiz anerkennt und vollstreckt unter gewissen Bedingungen auch von ausländischen Gerichten ergangene Urteile.
- **Behörde bestimmt das anwendbare Recht nach eigenem Recht:**
  Schweizer Zivilgerichte wenden etwaige internationale ankommen sowie das Bun-

desgesetz über das internationale Privatrecht (IPRG) an um das anzuwendende Recht zu bestimmen.
Schweizer Verwaltungs- und Strafbehörden wenden das Territorialprinzip an.

Remark 1.8. Rechtliche Vorkehrungen:

- Rechtswahl in B2B-Verträgen
- Günstiger Standort des eigenen Unternehmens (EU/nicht-EU/EU-Land)
- Disclaimer
- Abstimmung des Angebots auf die wichtigsten Rechtsordnungen
- Abstimmung des Angebots auf die strengsten Rechtsordnungen
- Günstige Wahl des Server-Standorts
- Günstige Wahl des Providers

1.3 Beispiele

Example 1.9. Konsumentenverträge: Unterliegen strengen Sonderregeln zum Schutz von Konsumenten. Kunden können bei grenzüberschreitenden Online-Geschäften oft an ihrem Wohnsitz klagen und sich auf das Recht ihres Aufenthaltsortes berufen (z. B. deutsches Konsumentenschutzrecht für Kunden aus Deutschland)

Example 1.10. Unerlaubte Handlung: Auf Schadenersatz geklagt werden kann in der Schweiz i.d.R. am Ort de Beklagten oder am Hanldungs- oder Erfolgsort. Falls der Täter je erwischt wird. Bis dahin verfolgen die Behörden am Ort des Opfers die Straftat.

Example 1.11. Urheberrecht: Immaterialgüterrechte unterstehen grundsätzlich dem Recht des Staates, für den der Schutz beansprucht wird (Art. 110 IPRG).

Example 1.12. Aufsichtsrecht: Unterliegt dem Territorialitätsprinzip bzw. dem Auswirkungsprinzip (z. B. Verbot von Alkoholwerbung für Jugendliche in der Schweiz).

2 Schutz fremder und eigener Inhalte

2.1 Einführung und Beispiele

Example 2.1. Aktuelle Fragestellungen und Beispiele:

- Affen-Selfie (Wem gehören die Rechte?)
- KI-Training mit geschützten Daten
- KI ersetzt Online-Informationsdienste mit deren eigenen Inhalten
- Gibt es ein Opt-Out-Recht für KI-Training?

Remark 2.2. Verschiedene Gesetze regeln den Schutz von Inhalten und weisen unterschiedliche Ansätze auf. Relevante Rechtsgebiete sind unter anderem:

- Urheberrechtsgesetz
- Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
- Obligationenrecht
- Markenschutz
- Datenschutz

2.2 Das Urheberrecht

Definition 2.3. Urheberrecht: Das Urheberrecht schützt eine schöpferische Leistung. Der Urheber hat das Recht, über die Verwendung dieser Leistung zu bestimmen.

Remark 2.4. Was schützt das Urheberrecht?
Der Weg von der Idee zur Verkörperung: Idee / Gedanke / Information → Formulierung / Umsetzung → Verkörperlichung.
Das Urheberrecht schützt die **Formulierung bzw. Umsetzung**.
"Schutzfähig ist nur der bestimmte Ausdruck eines Gedankens. Erst seine konkrete Verkörperung macht das Werk aus."

Definition 2.5. Bedingungen für urheberrechtlichen Schutz: Damit ein Werk geschützt ist, müssen grundsätzlich folgende Bedingungen erfüllt sein:

- **Geistige Schöpfung:** Es muss ein Gestaltungswille bzw. eine bewusste Kreation vorliegen.
- **Individueller Charakter:** Das Werk muss sich abheben und kreativ sein.

Remark 2.6. Neuerung 2020 (Lichtbildschutz): Gemäss dem neuen Gesetz von 2020 benötigen Fotografien (z.B. von dreidimensionalen Objekten) keinen individuellen Charakter mehr, um rechtlich geschützt zu sein.

2.3 Verwertungs- und Persönlichkeitsrechte

Definition 2.7. Urheberpersönlichkeitsrechte: Schützen die persönliche Beziehung des Urhebers zum Werk. Dazu gehören das Recht auf Autorennennung, das Recht über die Erstveröffentlichung zu entscheiden sowie der Schutz vor Entstellung oder Beeinträchtigung des Werkes.

Remark 2.8. Verwertungsrechte (Art. 10 & 11 URG): Der Urheber bestimmt allein, ob, wann und wie das Werk verwendet wird.

- Vervielfältigungs-, Verbreitungs-, Vermiet-, Vortrags-, Vorführ-, Sende- und Wiedergaberecht.
- Bearbeitungsrecht (z.B. Softwarewartung).
- Generalklausel erfasst auch neuartige Nutzungen (z.B. Framing im Web).
- Schutzdauer: 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers (50 Jahre bei Computerprogrammen und Fotos ohne individuellen Charakter).

Definition 2.9. Verwandte Schutzrechte: Schutzrechte für Leistungen, die nicht zwingend eigene Werke darstellen:

- **Ausübende Künstler (Interpreten):** Recht auf Wahrnehmbarmachung, Aufnahme, Vervielfältigung und Verbreitung ihrer Darbietung.
- **Hersteller von Ton- und Tonbildträgern:** Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung der Aufnahmen.
- **Sendeunternehmen:** Recht auf Weitersendung und Aufnahme ihrer Sendungen.

2.4 Beschaffung von Rechten und Lizenzierung

Definition 2.10. Lizenzierung vs. Übertragung:

- **Lizenzierung:** Einräumung der Befugnis, das Werk auf bestimmte Weise zu nutzen. Der Rechteinhaber behält seine Rechte.
- **Übertragung (Art. 16 URG):** Vollständige Abtretung der vermögensrechtlichen Befugnisse.

Remark 2.11. Urheberrecht im Arbeits- und Auftragsverhältnis:

- Rechte gehen nicht automatisch auf den Arbeitgeber über.
- **Ausnahme (Art. 17 URG):** Computerprogramme, die Arbeitnehmer in Ausübung dienstlicher Pflichten schaffen, stehen dem Arbeitgeber zu.
- Bei Kunden/Aufträgen bestimmt sich der Umfang der Nutzungsrechte nach dem Vertragszweck (Zweckübertragungstheorie; im Zweifel verbleiben Rechte beim Urheber).

Remark 2.12. Verwertungsgesellschaften (Art. 40 ff. URG): Staatlich zugelassene Organisationen (z.B. ProLitteris, SUISA, Suissimage) zur kollektiven Rechteverwertung im Monopolbereich (z.B. Leerträgervergütung, Kabelweitersendung) und Marktbereich.

2.5 Haftung von Plattformen und Hosting-Diensten

Remark 2.13. Hosting-Provider-Pflichten (Art. 39d URG & EU-Recht):

- Pflicht zur Verhinderung der erneuten rechtswidrigen Zugänglichmachung ("Notice and Takedown" / "Stay down"), wenn der Dienst eine besondere Gefahr für Verletzungen geschaffen hat.
- **EU-Urheberrechtsreform (Art. 17):** Plattformen haften für Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer, ausser sie weisen nach, dass sie ausreichende Bemühungen für Lizenzen und technische Schutzmassnahmen (Upload-Filter) unternommen haben.

2.6 Gesetzliche Schranken und Digital Rights Management

Definition 2.14. Schranken des Urheberrechts: Gesetzlich erlaubte Verwendungen geschützter Werke ohne vorherige Zustimmung des Urhebers:

- **Eigengebrauch (Art. 19 URG):** Nutzung im persönlichen Kreis, durch Lehrpersonen im Unterricht oder betriebsintern zur Information/Dokumentation. Download zum Eigengebrauch ist in der Schweiz legal, Upload/Anbieten jedoch rechtswidrig.
- **Zitatrecht (Art. 25 URG):** Veröffentlichte Werke dürfen zur Erläuterung/Veranschaulichung im erforderlichen Umfang mit Quellenangabe zitiert werden.
- **Parodie & Karikatur:** Abwandlungen eines Werks zur humorvollen oder kritischen Auseinandersetzung sind zulässig.
- **Erschöpfungsgrundsatz (Art. 12 URG):** Wurde ein Werkexemplar veräusserungsgemäss verkauft, darf es weiterverkauft werden (gilt auch für Online-Kopien von Software).

- **Weitere Schranken:** Berichterstattung über aktuelle Ereignisse, Wissenschaftsschranke (Art. 24d URG) und vorübergehende Vervielfältigungen (Art. 24a URG).

Remark 2.15. Digital Rights Management (DRM, Art. 39a & 39c URG):

- Das Umgehen wirksamer technischer Schutzmassnahmen ist verboten.
- Elektronische Informationen zur Rechteverwaltung (z.B. digitale Wasserzeichen, Copyright- Vermerke) dürfen weder entfernt noch verändert werden.

2.7 KI und Urheberrecht

Remark 2.16. Training von KI-Sprachmodellen (LLMs):

- Das Training dient in der Regel nicht dem "menschlichen Genuss" des Werks und führt bei hinreichender Zerlegung/Transformation nicht zu einer klassischen Kopie im Modell (Werk verblasst).
- Mögliche Schranken: Betrieblicher Eigengebrauch (Art. 19 URG) oder Wissenschaftsschranke (Art. 24d URG), sofern kein Re-Memorisieren stattfindet.
- **KI-Outputs:** KI-generierter Content ist nur urheberrechtlich geschützt, wenn der menschliche Prompt dem Output eine ausreichend individuelle Prägung verleiht.

2.8 Rechtsfolgen und Schutz ausserhalb des URG

Remark 2.17. Rechtsfolgen bei Urheberrechtsverletzungen:

- **Zivilrecht:** Schadenersatz (nach nachgewiesenem Schaden oder Lizenzanalogie) sowie Gewinnherausgabe.
- **Strafrecht (Art. 67 ff. URG):** Vorsätzliche Verletzungen werden mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet (inkl. Eventualvorsatz und Gehilfenschaft).

Remark 2.18. Schutz ausserhalb des Urheberrechts:

- **Lauterkeitsrecht (Art. 5 lit. c UWG):** Unlauter handelt, wer das marktreife Arbeitsergebnis eines anderen ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische Reproduktionsverfahren (z.B. Screen Scraping von Inseraten) übernimmt und verwertet.
- **Nutzungsbedingungen (AGB):** Binden Besucher von Webseiten grundsätzlich nur, wenn eine gültige Vertragsbeziehung zustande gekommen ist (z.B. durch Registrierung).

2.9 Domain-Namen

2.9.1 Grundlagen und Aufbau

Definition 2.19. Domain-Name: Weltweit eindeutige, menschenlesbare Adresse zur Identifikation und Adressierung von Rechnern und Diensten im Internet (wird über das DNS in IP-Adressen aufgelöst).

Remark 2.20. Hierarchischer Aufbau:

- **Top-Level-Domain (TLD):** Oberste Ebene der Namenshierarchie:
  - *ccTLD (country code):* Länderspezifisch (z.B. `.ch`, `.de`)
  - *gTLD (generic):* Generisch (z.B. `.com`, `.org`, `.swiss`)
- **Second-Level-Domain (SLD):** Der eigentliche gewählte Name (z.B. `ethz` in `ethz.ch`).
- **Subdomains:** Weitere Untergliederungen (z.B. `moodle.ethz.ch`).

2.9.2 Vergabesystem und Akteure

Remark 2.21. Akteure bei der Domain-Vergabe:

- **ICANN:** Globale Non-Profit-Organisation, koordiniert das Domain Name System und die Root-Zone weltweit.
- **Nationale Ordnung (Registry):** Verwaltet die Datenbank der jeweiligen TLD (z.B. SWITCH bzw. BAKOM für `.ch`).
- **Händler (Registrar):** Akkreditierte Verkäufer (z.B. Hostpoint, Infomaniak), über die Endkunden Domains registrieren.
- **Registrant:** Der Endkunde bzw. Domain-Halter.

2.9.3 Rechtliche Natur und Vergabe

Definition 2.22. First come, first served: Domain-Namen werden nach dem Prioritätsprinzip vergeben: Wer eine freie Domain zuerst anmeldet, erhält den Zuschlag. Die Registrierungsstellen führen keine Vorprüfung auf allfällige Marken- oder Namensrechte durch.

Important 2.23. Dienstleistung, nicht Eigentum!
An einem Domain-Namen erwirbt man **kein Sacheigentum** (kein Eigentum im Sinne von Art. 641 ZGB).
Es handelt sich um eine rein **vertragliche Dienstleistung**: Ein schuldrechtliches, relatives Nutzungsrecht auf Eintragung und Routing im DNS gegen Bezahlung einer

periodischen Gebühr.

2.9.4 Kennzeichenfunktion und Schutzrechte

Definition 2.24. Kennzeichenfunktion von Domain-Namen: Obwohl Domain-Namen technisch primär der Adressierung dienen, fungieren sie im geschäftlichen Verkehr als Erkennungs- und Unterscheidungszeichen. Sie wirken faktisch wie Namen oder Kennzeichen. Daher muss bei der Registrierung und Nutzung ein **hinreichender Abstand** zu bereits bestehenden Schutzrechten Dritter gewahrt werden, um Verwechslungsgefahr zu vermeiden.

Remark 2.25. Anwendbare Rechtsgrundlagen bei Konflikten:

- **Namensschutz (Art. 29 ZGB):** Schützt den Namen von natürlichen und juristischen Personen sowie Gemeinwesen vor unbefugter Namensanmassung. Gilt **branchenunabhängig**.
- **Markenschutz (MSchG):** Schützt eingetragene Kennzeichen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen. Gilt grundsätzlich **branchenabhängig** (Spezialitätsprinzip: Schutz nur für die eingetragenen Klassen; Ausnahme: berühmte Marken gemäss Art. 15 MSchG).
- **Lauterkeitsrecht (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG):** Verbietet unlautere Verhaltensweisen, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (sowie unlautere Kundenabfangung oder Rufausbeutung).
- **Firmenrecht (Art. 956 OR):** Schützt die im Handelsregister eingetragene Geschäftsfirma vor unbefugtem Gebrauch durch Dritte.

2.9.5 Rechtsverletzung und Verwechslungsgefahr

Remark 2.26. Rechtsverletzung durch Fehlleitung (Initial Interest Confusion):
Eine Rechtsverletzung (insbesondere nach UWG oder Kennzeichenrecht) kann bereits dann vorliegen, wenn Suchende oder Kunden, die gezielt nach dem berechtigten Original suchen, durch den Domain-Namen auf eine falsche Website fehlgeleitet werden (**Kundenabfangung**).
Unerheblich ist dabei grundsätzlich, ob der Internetnutzer beim Betrachten des Website-Inhalts bemerkt, dass es sich nicht um die gesuchte Originalseite handelt, da dessen Aufmerksamkeit bereits unlauter abgelenkt wurde.

2.9.6 Sonderkonstellationen und Schranken

Remark 2.27. Spezialfälle im Domainrecht:

- **Gemeindenamen und Hoheitszeichen (z.B. `gemeindename.ch`):** Namen von Gemeinwesen (Kantone, Gemeinden, Städte) geniessen Namensschutz (Art. 29 ZGB). Private dürfen sich Gemeindenamen in der Regel nicht als Domain

registrieren, da das Publikum dahinter eine offizielle behördliche Website vermutet (**hohe Verkehrserwartung**).

- **Beschreibende Begriffe und Gemeingut:** Rein beschreibende Gattungsbezeichnungen (z.B. `velo.ch`, `recht.ch`) gehören zum Gemeingut (Freihaltebedürfnis) und geniessen mangels Unterscheidungskraft in der Regel keinen Markenschutz. Bei reinen Sachbezeichnungen gilt strikt das Prioritätsprinzip (*First come, first served*), sofern keine unlautere Behinderung oder Täuschung vorliegt.
- **Kollision gleichwertiger Rechte (Gleichnamige):** Haben mehrere Parteien ein legitimes Recht am gleichen Namen bzw. Zeichen (z.B. gleiche Familiennamen oder Firmen in unterschiedlichen Branchen):
  - *Grundsatz:* Es gilt das Prioritätsprinzip (*First come, first served*).
  - *Korrektiv:* Sofern eine Partei eine deutlich überwiegende **Verkehrserwartung** für sich beanspruchen kann (z.B. überragende Bekanntheit) oder die Registrierung rechtsmissbräuchlich bzw. sittenwidrig erfolgte, kann ein Vorrang bestehen.
- **Nutzung durch Händler, Vertriebspartner und Importeure:** Dritte dürfen fremde Marken nutzen, um auf angebotene Originalwaren, Ersatzteile oder Dienstleistungen wahrheitsgemäss hinzuweisen (beschreibender Markengebrauch / Erschöpfungsgrundsatz). Es darf jedoch nicht der irreführende Eindruck erweckt werden, man sei die Markeninhaberin selbst oder eine wirtschaftlich verbundene Niederlassung.

2.9.7 Streitbeilegung und Schlichtungsverfahren

Definition 2.28. Alternative Streitbeilegung (Dispute Resolution): Schnelle, kostengünstige und spezialisierte Verfahren zur Beilegung von Domain-Streitigkeiten ausserhalb der ordentlichen staatlichen Zivilgerichte.

Remark 2.29. Verfahren im Überblick:

- **UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy):**
  - Globales Schlichtungsverfahren der ICANN für generische Top-Level-Domains (gTLDs wie `.com`, `.org`, `.net`) sowie diverse ccTLDs.
  - Streitigkeiten werden massgeblich über das Schiedszentrum der **WIPO** (World Intellectual Property Organization in Genf) geführt.
  - *Voraussetzungen (kumulativ):* Die Domain ist identisch oder verwechslungsfähig ähnlich zu einer Marke des Klägers, der Halter hat keine eigenen Rechte oder berechtigten Interessen und die Domain wurde bösgläubig registriert und wird bösgläubig genutzt (*bad faith* / Cybersquatting / Domaingrabbing).
- **SWITCH-Streitbeilegungsverfahren (für `.ch` und `.li`):**
  - Spezifisches Verfahren für Schweizer und Liechtensteiner Domains, eben-

falls unter administrativer Leitung der **WIPO**.

- Zweistufiges Verfahren: Zunächst eine Schlichtungsverhandlung (Mediation); falls keine Einigung erzielt wird, entscheidet ein unabhängiger Fachexperte.
- *Voraussetzungen:* Die Zuteilung oder Verwendung der Domain stellt eine Verletzung eines Kennzeichenrechts nach schweizerischem Recht dar (Marken-, Namens-, Firmenrecht oder UWG) und der Inhaber besitzt kein überwiegendes schutzwürdiges Eigeninteresse.

3 Haftung und Rechtsverfolgung im Netz

3.1 Ausgangslage und Cyberrisiken

Example 3.1. Cyberrisiken (z.B. Ransomware-Angriffe):
Angreifer verschlüsseln geschäftskritische Daten oder legen IT-Systeme lahm und fordern Lösegeld für die Freigabe (oder drohen bei *Double Extortion* mit der Veröffentlichung gestohlener Daten). Dies führt zu massiven Betriebsunterbrüchen, Wiederherstellungskosten, Reputationsschäden und möglichen Ansprüchen geschädigter Dritter.

Important 3.2. Grundproblem der Rechtsverfolgung im Netz:
Die eigentlichen Täter (z.B. Hacker oder Urheber von Rechtsverletzungen) agieren meist **anonym** und aus dem **Ausland**. Sie sind rechtlich und faktisch kaum greifbar.
→ Geschädigte und Behörden nehmen daher für die Haftung und Rechtsdurchsetzung primär greifbare Akteure in der Schweiz ins Visier, insbesondere betroffene **Unternehmen, deren Organe sowie IT-Dienstleister und Provider**.

3.2 Grundvoraussetzungen der Haftung

Theorem 3.3. Prinzip der gesetzlichen Grundlage:
Jede rechtliche Verantwortlichkeit (straf- wie zivilrechtlich) setzt eine **gesetzliche Grundlage** voraus. Für das Greifen einer Rechtsfolge müssen grundsätzlich drei Ebenen erfüllt sein:

1. **Objektiver Tatbestand:** Äussere Merkmale einer Rechtsverletzung oder Straftat (Tathandlung, Taterfolg, Kausalzusammenhang).
2. **Subjektiver Tatbestand (Verschulden):** Innere Einstellung bzw. Vorwerfbarkeit:
   - *Vorsatz:* Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung.
   - *Eventualvorsatz:* Ernstnehmen der Möglichkeit des Erfolgs und Inkaufnahme desselben ("billigend in Kauf nehmen").
   - *Fahrlässigkeit:* Pflichtwidrige Unvorsichtigkeit (Missachtung der nach den Umständen und persönlichen Verhältnissen gebotenen Sorgfalt).
3. **Fehlen von Rechtfertigungsgründen:** Keine gesetzliche Erlaubnis, keine gültige Einwilligung des Verletzten, keine Notwehr oder Notstand.

3.2.1 Strafrechtliche Verantwortlichkeit

Remark 3.4. Typische Cyber-Straftatbestände der Angreifer (StGB):
Im Strafrecht gilt ein strenges Legalitätsprinzip (*nulla poena sine lege*, Art. 1 StGB); strafbar ist in der Regel nur vorsätzliches (inkl. eventualvorsätzliches) Handeln, sofern das Gesetz Fahrlässigkeit nicht ausdrücklich unter Strafe stellt. Angreifer machen sich insbesondere strafbar wegen:

- **Unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem (Hacking, Art. 143bis StGB):** Eindringen in fremde, gegen unbefugten Zugriff besonders gesicherte Systeme auf elektronischem Weg.
- **Unbefugte Datenbeschaffung (Art. 143 StGB):** Beschaffen elektronisch gespeicherter, nicht für den Täter bestimmter und besonders gesicherter Daten in Bereicherungsabsicht.
- **Datenbeschädigung (Art. 144bis StGB):** Unbefugtes Ändern, Löschen oder Unbrauchbarmachen elektronisch gespeicherter Daten (z.B. Verschlüsselung durch Ransomware, DDoS-Attacken) sowie das Herstellen/Verbreiten von Schadsoftware (Malware).
- **Erpressung (Art. 156 StGB) und Nötigung (Art. 181 StGB):** Erzwingen einer Lösegeldzahlung (z.B. in Kryptowährungen) durch Androhung ernstlicher Nachteile (Datenverlust oder Veröffentlichung sensibler Daten).
- **Betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 StGB):** Vermögensverschiebung durch unrichtige, unvollständige oder unbefugte Verwendung von Daten (z.B. Phishing).

3.2.2 Zivilrechtliche Haftung (Schadenersatz)

Definition 3.5. Voraussetzungen der zivilrechtlichen Haftung (Art. 41 ff. OR / Art. 97 ff. OR):
Damit ein Geschädigter zivilrechtlich Schadenersatz fordern kann, müssen **vier Voraussetzungen kumulativ** nachgewiesen werden:

1. **Vermögensschaden:** Nachgewiesene, unfreiwillige Vermögensverminderung (Differenztheorie: Bestandesabnahme, Passivenzunahme oder entgangener Gewinn).
2. **Widerrechtlichkeit oder Vertragswidrigkeit:**
   - *Ausservertraglich (Delikt, Art. 41 OR):* Verletzung eines absolut geschützten Rechtsguts (z.B. Eigentum, Persönlichkeit, Urheberrecht) oder Verstoss gegen eine spezifische Schutznorm.
   - *Vertraglich (Art. 97 OR):* Verletzung einer Pflicht aus einem bestehenden Schuldverhältnis (z.B. Hosting-Vertrag, SLA, Sorgfaltspflichten).
3. **Adäquater Kausalzusammenhang:** Das schädigende Verhalten muss nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet sein, einen Erfolg von der Art des eingetretenen herbeizuführen.
4. **Verschulden (Absicht oder Fahrlässigkeit):** Subjektive Vorwerfbarkeit (im Vertragsrecht wird das Verschulden gesetzlich vermutet, d.h. der Schuldner muss sich exkulpieren, Art. 97 Abs. 1 OR; im Deliktsrecht muss der Geschädigte das Verschulden beweisen).

3.3 Haftungsverteilung, Rückgriff und Organverantwortung

3.3.1 Haftung im Unternehmen und Regress

Remark 3.6. Haftung für eigenes Verhalten, Angestellte und Hilfspersonen:

- **Primäre Unternehmenshaftung:** Unternehmen haften im Aussenverhältnis gegenüber Kunden und Dritten primär selbst für Schäden, die durch ihre Organe (Art. 55 ZGB / Art. 722 OR), ihre Arbeitnehmer oder beigezogene Hilfspersonen (z.B. externe IT-Dienstleister, Subunternehmer) verursacht werden.
- **Vertragliche Hilfspersonenhaftung (Art. 101 OR):** Wer die Erfüllung einer Schuldpflicht durch eine Hilfsperson (z.B. Mitarbeiter, Cloud-Anbieter) vornehmen lässt, haftet dem Vertragspartner für den von der Hilfsperson in Ausübung ihrer Verrichtung verursachten Schaden ohne eigenes Verschulden.
- **Deliktische Geschäftsherrenhaftung (Art. 55 OR):** Als Geschäftsherr haftet das Unternehmen für Schäden durch Arbeitnehmer/Hilfspersonen, sofern es nicht nachweist, dass es alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat (**Cura in eligendo, instruendo et custodiendo**).
- **Eingeschränkter Rückgriff (Regress auf Arbeitnehmer, Art. 321e OR):** Hat das Unternehmen den Schaden im Aussenverhältnis gedeckt, ist der interne Rückgriff auf fehlbare Angestellte (z.B. Mitarbeiter klickt auf Phishing-Mail) stark eingeschränkt. Bei leichter Fahrlässigkeit (Alltagsversehen) trägt in der Regel der Arbeitgeber das Betriebsrisiko; ein voller oder teilweiser Rückgriff ist meist nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz unter Berücksichtigung des Berufsrisikos, des Bildungsgrades und der Lohnhöhe zulässig.

3.3.2 Verantwortung des Verwaltungsrats und Sorgfaltsmassstab

Definition 3.7. Verantwortung des Verwaltungsrats (Art. 716a & Art. 754 OR):
Der Verwaltungsrat (VR) trägt die unübertragbare und unentziehbare Oberleitung des Unternehmens, einschliesslich der Ausgestaltung des Risikomanagements und der Internen Kontrolle (IKS).
Delegiert der VR operative Aufgaben (z.B. IT-Security an die Geschäftsleitung oder den CISO), haftet er für die sorgfältige:

1. **Auswahl (*Cura in eligendo*):** Einsetzen fachlich und persönlich qualifizierter Personen.
2. **Instruktion (*Cura in instruendo*):** Klare Weisungen, Richtlinien, Sicherheitskonzepte und Zielvorgaben.
3. **Überwachung (*Cura in custodiendo*):** Regelmässige Kontrolle, Audits, Reporting und Einschreiten bei Missständen.

Definition 3.8. Three Lines of Defence Modell (Risikomanagement & Compliance):
Anerkanntes Governance-Modell zur systematischen Steuerung von Risiken (insb.

Cyber- und IT-Risiken) und zur Sicherstellung der Compliance im Unternehmen:

1. **1st Line of Defence (Operatives Management & Fachabteilungen):** Die operativen Einheiten und der IT-Betrieb identifizieren, bewerten und steuern Risiken direkt im Tagesgeschäft durch technische und organisatorische Schutzmassnahmen (z.B. Patch-Management, Firewalls, Zugriffskontrollen).
2. **2nd Line of Defence (Risikomanagement, Compliance & IT-Security/CISO):** Überwacht und unterstützt die erste Linie, gibt Sicherheitsrichtlinien und Rahmenwerke vor und prüft die Einhaltung gesetzlicher sowie interner Vorgaben.
3. **3rd Line of Defence (Interne Revision / Internal Audit):** Prüft völlig unabhängig von den operativen Prozessen die Wirksamkeit der ersten und zweiten Verteidigungslinie und rapportiert direkt an den Verwaltungsrat (bzw. das Audit Committee).

Important 3.9. Sorgfaltsmassstab und Branchenstandards (Ausschluss der Fahrlässigkeit):
Es gibt im Netz keine absolute (100%-ige) Sicherheit gegen Cyberangriffe.
Grundsatz: Wer anerkannte **Branchenstandards** (Stand der Technik, z.B. ISO 27001, NIST Cybersecurity Framework, IKT-Minimalstandard des Bundes) angemessen umsetzt, eine funktionierende Governance (z.B. *Three Lines of Defence*) pflegt und die gebotene Sorgfalt walten lässt, **haftet nicht wegen Fahrlässigkeit**, selbst wenn es dennoch zu einem erfolgreichen Angriff oder Sicherheitsvorfall kommt.

3.4 Provider-Haftung und Rechtsdurchsetzung

Theorem 3.10. Grundprinzip der Provider-Verantwortlichkeit:
In der Schweiz existiert kein allgemeines Spezialgesetz für sämtliche Online-Provider (anders als z.B. der Digital Services Act in der EU); es gelten die allgemeinen zivil- und strafrechtlichen Regeln (mit einzelnen Spezialnormen wie Art. 39d URG).
Als Faustregel gilt: **Je näher ein Provider an den Daten und Inhalten ist (Kontroll- und Einflussmöglichkeit), desto weitreichender sind seine Prüf-, Sorgfalts- und Handlungspflichten.**

Remark 3.11. Abstufung nach Provider-Typen:

- **Access-Provider (Zugangsvermittler, z.B. Swisscom, Sunrise):**
  Vermitteln lediglich den technischen Zugang zum Internet (reine Durchleitung / *Mere Conduit*) und haben weder Kenntnis noch Kontrolle über die transportierten Datenpakete.
  → Sie haften **in der Regel nicht** für Rechtsverletzungen Dritter, die über ihren Zugang begangen werden, und sind grundsätzlich auch nicht zu Netzsperren wegen zivilrechtlicher Ansprüche verpflichtet (Bundesgerichtspraxis; Ausnahmen nur bei expliziter gesetzlicher Grundlage wie Geldspiel-Sperrlisten

nach BGS).

- **Hosting-Provider (Speicherplatzanbieter & Plattformen, z.B. Webhoster, Cloud-Anbieter, Social Media):**
  Speichern fremde Inhalte im Auftrag ihrer Nutzer auf eigenen Servern und halten diese zum Abruf bereit.
  → Sie haben zwar **keine allgemeine Vorab-Prüfpflicht** (keine Pflicht zur proaktiven Überwachung sämtlicher hochgeladener Inhalte), sind jedoch zur **Entfernung rechtswidriger Inhalte verpflichtet**, sobald sie konkrete Kenntnis von einer Rechtsverletzung erlangen (**Notice-and-Takedown**-Prinzip, vgl. auch Art. 39d URG für Urheberrechte mit *Stay-down*-Pflicht bei besonderer Gefahr).
  → Für Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche (z.B. Löschung persönlichkeitsverletzender Beiträge gemäss Art. 28 ZGB) können Hosting-Provider als Mitwirkende direkt ins Recht gefasst werden, auch ohne eigenes Verschulden.
- **Content-Provider (Inhalteanbieter):**
  Stellen eigene Inhalte ins Netz oder machen sich fremde Inhalte zu eigen.
  → Sie tragen die **volle eigene zivil- und strafrechtliche Verantwortlichkeit** für die publizierten Inhalte.

3.5 Risiko von Cloud-Providern und ausländischem Behördenzugriff

Definition 3.12. US CLOUD Act vs. Schweizer Souveränität:
Der US CLOUD Act (*Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act*) ermächtigt US-Behörden, von IT-Anbietern mit US-Bezug (z.B. Microsoft, AWS, Google) die Herausgabe von Daten zu verlangen – unabhängig davon, wo die Server physisch stehen (selbst bei Rechenzentren in der Schweiz):

- **Kollision mit Art. 271 StGB (Verbotene Handlungen für einen fremden Staat):** Gemäss Art. 271 Ziff. 1 StGB macht sich strafbar, wer auf schweizerischem Gebiet ohne Bewilligung Handlungen vornimmt, die einer Behörde oder einem Beamten zukommen.
- **Rechtshilfeweg:** Ausländische Behörden müssen Daten grundsätzlich über den offiziellen internationalen Rechtshilfeweg anfordern. Eine direkte Datenherausgabe an US-Behörden unter Umgehung des Schweizer Rechtshilfeverfahrens verletzt die Schweizer Souveränität und birgt das Risiko einer Strafbarkeit nach Art. 271 StGB.

Theorem 3.13. Berufsgeheimnisse in der Cloud (Art. 321 StGB, Art. 47 BankG):
Berufsgeheimnisträger (Ärzte, Anwälte, Notare, Banken) unterliegen strengen strafbewehrten Schweigepflichten. Bei der Auslagerung vertraulicher Daten in die Cloud stellt sich die Frage nach einer unbefugten Offenbarung:

- **Strafbarkeit nur bei Vorsatz:** Die Verletzung des Berufsgeheimnisses nach Art. 321 StGB ist ein reines Vorsatzdelikt. Fahrlässiges Handeln ist **strafrechtlich**

straflos (führt aber zu zivilrechtlicher Haftung nach Art. 97 OR).

- **Eventualvorsatz (→ strafbar):** Der Geheimnisträger hält einen unbefugten Zugriff Dritter oder ausländischer Behörden (z.B. via US CLOUD Act) für ernsthaft möglich und nimmt diesen billigend in Kauf (z.B. bei unverschlüsselter Speicherung sensibler Akten bei US-Hyperscalern).
- **Bewusste Fahrlässigkeit (→ straflos nach Art. 321 StGB):** Der Geheimnisträger erkennt das abstrakte Zugriffsrisiko, vertraut jedoch pflichtwidrig und leichtfertig darauf, dass ein unbefugter Zugriff ausbleibt (z.B. gestützt auf technische Sicherheitsvorkehrungen).

Important 3.14. Praktische Schutz- und Risikominderungsmassnahmen:

- **Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (BYOK):** Starke Verschlüsselung der Daten vor dem Upload, wobei der Schlüssel ausschliesslich beim Schweizer Geheimnisträger verbleibt (*Bring Your Own Key*). Der Provider kann selbst bei Herausgabeanordnungen nur unlesbaren Ciphertext liefern.
- **Sovereign Cloud / Schweizer Provider:** Speicherung bei Schweizer Anbietern ohne US-Mutterkonzern, die keinem US-Rechtszugriff unterliegen.
- **Vertragliche Klauseln:** Pflicht des Providers zur sofortigen Kundenbenachrichtigung bei behördlichen Anfragen und zur Ausschöpfung aller Rechtsmittel.

4 Verträge im Netz

4.1 Vertragsschluss und Konsensus im E-Commerce

Definition 4.1. Ablauf des Vertragsschlusses im Webshop: Ein Vertrag entsteht durch gegenseitige, übereinstimmende Willensäusserung (Konsens, Art. 1 OR):

1. **Einladung zur Offerte (*invitatio ad offerendum*):** Die Präsentation von Waren oder Dienstleistungen auf einer Website oder in einem Webshop stellt in der Regel noch keinen rechtlich verbindlichen Antrag dar (Art. 7 Abs. 2 OR), sondern lediglich eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden, seinerseits eine Offerte abzugeben.
2. **Angebot (Bestellung):** Durch das Anklicken des Bestell-Buttons (z.B. „Zahlungspflichtig bestellen“) gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags ab.
3. **Annahme:** Der Vertrag kommt zustande, sobald der Händler das Angebot annimmt. Dies geschieht entweder durch eine ausdrückliche Annahmeerklärung (z.B. Auftragsbestätigung, Versandbestätigung per E-Mail) oder konkludent durch die tatsächliche Lieferung der Ware.

Important 4.2. Automatische Empfangsbestätigung $\neq$ Vertragsannahme: Die gesetzlich vorgeschriebene sofortige elektronische Bestätigung des Bestelleingangs (Art. 3 Abs. 1 lit. s Ziff. 4 UWG) dient nur der Dokumentation des Eingangs und stellt noch keine Annahme der Offerte dar, es sei denn, der Text erklärt dies ausdrücklich.

Theorem 4.3. Willensmängel und Irrtümer im E-Commerce (Art. 23 ff. OR): Kommt es bei der Erfassung oder automatisierten Verarbeitung im Webshop zu Preis- oder Produktfehlern, stellt sich die Frage der Vertragsgültigkeit:

- **Wesentlicher Erklärungsirrtum (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 3 OR):** Weicht die abgegebene Erklärung unbewusst vom tatsächlichen Willen ab (z.B. Tippfehler bei der Dateneingabe, Datenbank-Synchronisationsfehler), liegt ein wesentlicher Erklärungsirrtum vor, wenn eine Leistung von erheblich grösserem oder geringerem Wert zugesagt wurde als beabsichtigt.
- **Rechtsfolge (Anfechtbarkeit):** Der Vertrag ist für den Irrenden unverbindlich, sofern er den Irrtum unverzüglich nach Entdeckung geltend macht (Art. 31 OR).
- **Fahrlässiger Irrtum und Schadenersatz (Art. 26 OR):** Beruht der Erklärungsirrtum auf eigener Fahrlässigkeit des Händlers, ist die Anfechtung dennoch wirksam; der Händler muss dem gutgläubigen Käufer jedoch den aus dem Dahinfallen des Vertrages erwachsenen Schaden (negatives Vertragsinteresse) ersetzen.
- **Praxisfall (Falsche Preisanschrift):** Bei offensichtlichen Preisfehlern (z.B. Microspot- oder Orell Füssli-Fall: Luxusartikel oder Bücher für CHF 0.– oder

ein Bruchteil des Marktpreises) fehlt es am Schutz des Käufers, wenn dieser nach Treu und Glauben erkennen musste, dass es sich um ein Versehen handelte (Rechtsmissbrauchsverbot, Art. 2 Abs. 2 ZGB).

Definition 4.4. Vertragsschluss durch KI-Agenten und Bots: Immer häufiger werden Verträge ganz oder teilweise durch automatisierte Systeme oder generative KI-Agenten initiiert, ausgehandelt oder abgeschlossen:

- **Rechtliche Zurechnung:** KI-Systeme besitzen keine eigene Rechtspersönlichkeit. Erklärungen, die ein KI-Agent abgibt, werden dem Betreiber (Unternehmen) nach den Grundsätzen des Erklärungsboten oder der Stellvertretung analog zugerechnet: Der Betreiber bedient sich des Systems als Werkzeug zur Willensäusserung.
- **Verbindlichkeit und Risiken:** Äussert ein Chatbot gegenüber einem Kunden Zusagen, Rabatte oder Vertragsbedingungen (z.B. durch Fehlinterpretationen oder Halluzinationen wie im Fall des Air-Canada-Chatbots), ist das Unternehmen grundsätzlich an diese Zusagen gebunden.
- **Schutzmöglichkeiten des Betreibers:**
  - Technische Restriktionen (Hard Limits bei Rabatten, strikte System-Prompts, Freigabevorbehalte durch Menschen bei kritischen Abschlüssen).
  - Transparenzhinweis, dass ein KI-System agiert.
  - Einbeziehung klarer AGB-Klauseln, wonach KI-Auskünfte unverbindlich sind und ein Vertrag erst mit menschlicher Bestätigung zustande kommt.

4.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Definition 4.5. Einbezug von AGB in den Vertrag: AGB sind vorformulierte Vertragsbestimmungen für eine Vielzahl von Verträgen. Sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie wirksam einbezogen wurden:

- **Vorheriger deutlicher Hinweis:** Der Kunde muss **vor** Abgabe seiner Vertragserklärung ausdrücklich auf die Geltung der AGB hingewiesen werden.
- **Zumutbare Kenntnisnahmemöglichkeit:** Dem Kunden muss es vor Vertragsschluss zumutbar möglich sein, vom Inhalt der AGB Kenntnis zu nehmen (z.B. über einen gut sichtbaren, funktionsfähigen Hyperlink direkt neben der Bestell-Checkbox).
- **Zustimmung (Opt-in):** Bestätigung durch aktives Anklicken einer Checkbox („Ich akzeptiere die AGB“). Vorauszugefüllte Checkboxen oder blosse Hinweise im Footer genügen für eine wirksame Einbindung oft nicht.

Theorem 4.6. Inhaltskontrolle von AGB: Nicht jede wirksam einbezogene Klausel ist auch rechtlich durchsetzbar:

- **Ungewöhnlichkeitsregel (Praxis):** Eine Klausel gilt als nicht vereinbart, wenn sie geschäftsfremden Charakter aufweist, der Kunde ihr nicht ausdrücklich zugestimmt hat und nach Treu und Glauben vernünftigerweise nicht mit einer solchen Bestimmung rechnen musste.
- **Gesetzliche Inhaltskontrolle (Art. 8 UWG):** Im Verhältnis zu Konsumentinnen und Konsumenten (B2C) sind AGB-Klauseln unlauter und damit **nichtig**, die in Treu und Glauben verletzender Weise ein erhebliches und ungerechtfertigtes Missverhältnis zwischen den vertraglichen Rechten und Pflichten zum Nachteil des Konsumenten begründen.
  Typische unzulässige Klauseln: Umfassende Haftungsausschlüsse für Kernpflichten, einseitige nachträgliche Preisänderungsrechte ohne Kündigungsoption, unzumutbare Gerichtsstandsklauseln.

4.3 Informationspflichten und Konsumentenschutz

Definition 4.7. Gesetzliche Informationspflichten im E-Commerce (Art. 3 Abs. 1 lit. s UWG): Wer Waren, Werke oder Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr anbietet, muss:

1. **Impressumspflicht:** Klare und vollständige Angaben über seine Identität und seine Kontaktadresse (einschliesslich E-Mail) machen.
2. **Transparenz der Schritte:** Auf die einzelnen technischen Schritte hinweisen, die zum Vertragsschluss führen.
3. **Korrekturmöglichkeiten:** Angemessene technische Mittel zur Verfügung stellen, mit denen Eingabefehler vor dem Absenden der Bestellung erkannt und korrigiert werden können (z.B. Bestellübersichtsseite).
4. **Unverzügliche Bestätigung:** Die Bestellung des Kunden unverzüglich auf elektronischem Weg (z.B. Bestätigungs-E-Mail) bestätigen.

Important 4.8. Kein gesetzliches Widerrufsrecht im Schweizer Online-Handel (Unterschied CH vs. EU):

- **EU-Recht:** Im europäischen Fernabsatzrecht (EU-Verbraucherrechte-Richtlinie) gilt ein zwingendes, mindestens **14-tägiges gesetzliches Widerrufsrecht** für Verbraucher bei Online-Käufen ohne Angabe von Gründen.
- **Schweizer Recht:** Das schweizerische Recht kennt **kein allgemeines Widerrufs- oder Rückgaberecht** für Online-Käufe! Das Widerrufsrecht für Konsumverträge gemäss Art. 40a ff. OR (14 Tage) gilt ausschliesslich für Haustürgeschäfte, Verkaufsfahrten und Telefonmarketing; Verträge im Webshop sind davon ausdrücklich ausgenommen. Ein Rückgaberecht im Schweizer Online-Handel existiert nur,

wenn der Händler es freiwillig (z.B. in den AGB) gewährt.

4.4 Beweis, Schriftform und Elektronische Signatur

Definition 4.9. Formvorschriften im Schweizer Recht (Art. 11 ff. OR):

- **Grundsatz der Formfreiheit (Art. 11 Abs. 1 OR):** Verträge bedürfen zu ihrer Gültigkeit nur dann einer besonderen Form, wenn das Gesetz dies vorschreibt oder die Parteien dies vereinbart haben. Die meisten E-Commerce-Kaufverträge sind formfrei und per Mausklick gültig.
- **Einfache Schriftlichkeit (Art. 13/14 OR):** Wo das Gesetz Schriftform verlangt (z.B. Lehrvertrag, Schenkungsversprechen, Zession Art. 165 OR, Konsumkreditvertrag), muss das Dokument eigenhändig von der verpflichteten Person unterschrieben werden. Eine blosse E-Mail oder ein Scan genügen diesem Erfordernis nicht.

Theorem 4.10. Qualifizierte elektronische Signatur (Art. 14 Abs. 2bis OR i.V.m. ZertES): Der eigenhändigen Unterschrift ist rechtlich ausschliesslich die **qualifizierte elektronische Signatur (QES)** gleichgestellt, die auf einem qualifizierten Zertifikat einer anerkannten Schweizer Zertifizierungsstelle beruht und mit einem qualifizierten elektronischen Zeitstempel versehen ist (gemäss Bundesgesetz über die elektronische Signatur, ZertES). Nur die QES erfüllt gesetzliche Schriftformerfordernisse digital.

Remark 4.11. Sorgfalts- und Haftungspflichten des Signaturinhabers (Art. 59a OR): Der Inhaber eines Signaturschlüssels ist gesetzlich verpflichtet, die Signierschlüsseldaten sorgfältig zu verwahren und vor Missbrauch durch Unbefugte zu schützen. Verletzt er diese Sorgfaltspflicht (z.B. Weitergabe der Signatur-PIN), haftet er Dritten für den daraus entstandenen Schaden, wenn diese auf die Gültigkeit der Signatur vertraut haben.

5 Datenschutzrecht (DSG)

5.1 Grundbegriffe und Geltungsbereich

Definition 5.1. Geltungsbereich des Schweizer Datenschutzgesetzes (revDSG): Das revidierte DSG bezweckt den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte natürlicher Personen, über die Personendaten bearbeitet werden (Art. 1 DSG). Juristische Personen fallen seit der Revision 2023 nicht mehr unter den Schutzbereich des DSG.

Definition 5.2. Kategorien von Daten:

- **Personendaten (Art. 5 lit. a DSG):** Alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen. Bestimmbar ist eine Person, wenn sie direkt oder über Zusatzwissen (z.B. Verknüpfung mit Logfiles, Cookie-IDs, dynamischen IP-Adressen oder Verhaltensmustern) identifiziert werden kann.
- **Besonders schützenswerte Personendaten (Art. 5 lit. c DSG):** Daten über:
  - religiöse, weltanschauliche, politische oder gewerkschaftliche Ansichten oder Tätigkeiten,
  - die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Zugehörigkeit zu einer Rasse oder Ethnie,
  - genetische Daten und biometrische Daten, die eine Person eindeutig identifizieren,
  - verwaltungs- und strafrechtliche Verfolgungen oder Sanktionen,
  - Massnahmen der sozialen Hilfe.

Remark 5.3. Anonymisierung vs. Pseudonymisierung:

- **Anonymisierung:** Der Personenbezug wird irreversibel vernichtet, sodass die betroffene Person von niemandem mehr identifiziert werden kann. Vollständig anonymisierte Daten fallen nicht mehr unter das DSG.
- **Pseudonymisierung:** Der Name oder Identifikator wird durch ein Pseudonym ersetzt (z.B. User-ID), wobei der Zuordnungsschlüssel getrennt aufbewahrt wird. Da der Personenbezug mit dem Schlüssel wiederhergestellt werden kann, bleiben pseudonymisierte Daten vollwertige Personendaten im Sinne des DSG.
- **Re-Identifikationsrisiko bei Big Data:** Bei umfangreichen Datenmengen genügt oft die Korrelation weniger Merkmale (z.B. PLZ, Geburtsdatum, Geschlecht), um scheinbar anonyme Datensätze eindeutig konkreten Personen zuzuordnen.

5.2 Bearbeitungsgrundsätze (Art. 6 und 7 DSG)

Theorem 5.4. Zwingende Bearbeitungsgrundsätze (Art. 6 DSG): Jede Datenbearbeitung muss den folgenden Grundsätzen genügen:

1. **Rechtmässigkeit:** Datenbearbeitungen dürfen nicht gegen Rechtsnormen verstossen.
2. **Treu und Glauben (Transparenz):** Die Datenbeschaffung und deren Zweck müssen für die betroffene Person erkennbar sein; keine heimliche oder irreführende Datenbeschaffung.
3. **Zweckbindung:** Personendaten dürfen nur zu dem Zweck beschafft werden, der bei der Beschaffung angegeben wurde, aus den Umständen ersichtlich oder gesetzlich vorgesehen ist.
4. **Verhältnismässigkeit:** Die Bearbeitung muss zur Erreichung des Zwecks geeignet und erforderlich sein (Datenminimierung: nur so viele Daten wie nötig bearbeiten und so früh wie möglich löschen).
5. **Richtigkeit:** Wer Personendaten bearbeitet, muss sich über deren Richtigkeit vergewissern; unrichtige Daten müssen korrigiert oder gelöscht werden.
6. **Datensicherheit (Art. 8 DSG):** Angemessene technische und organisatorische Massnahmen (TOMs) gegen unbefugte Bearbeitung, Verlust oder Zerstörung.

Important 5.5. Legalitätsprinzip und Opt-out im Schweizer Recht:
Die Bearbeitung von Personendaten ist grundsätzlich **erlaubt**, solange kein Bearbeitungsgrundsatz verletzt wird und kein Widerspruch der betroffenen Person vorliegt.

Eine explizite Einwilligung (Opt-in) ist nach Schweizer Recht nur erforderlich bei besonders schützenswerten Daten, hochriskantem Profiling oder wenn eine Persönlichkeitsverletzung vorliegt, die nicht durch ein überwiegendes privates/öffentliches Interesse oder Gesetz gerechtfertigt ist.

5.3 Rollenverteilung und Datenübermittlung

Definition 5.6. Verantwortlicher vs. Auftragsbearbeiter:

- **Verantwortlicher (Controller, Art. 5 lit. j DSG):** Die private Person oder das Bundesorgan, die allein oder zusammen mit anderen über den Zweck und die Mittel der Bearbeitung entscheidet. Trägt die Hauptverantwortung für die Einhaltung des DSG.
- **Auftragsbearbeiter (Processor, Art. 5 lit. k DSG):** Bearbeitet Personendaten ausschliesslich im Auftrag und nach Weisung des Verantwortlichen (z.B. Cloud-Provider, SaaS-Anbieter).
- **Auftragsbearbeitungsvertrag (AVV / DPA, Art. 9 DSG):** Die Del-

egation erfordert eine vertragliche oder gesetzliche Vereinbarung, die sicherstellt, dass der Auftragsbearbeiter Daten nur so bearbeitet, wie es der Verantwortliche selbst tun dürfte, und die Datensicherheit gewährleistet. Sub-Auftragsbearbeiter bedürfen der vorherigen Genehmigung.

Theorem 5.7. Bekanntgabe von Personendaten ins Ausland (Art. 16 f. DSG): Personendaten dürfen grundsätzlich nur dann ins Ausland bekanntgegeben werden, wenn der Zielstaat einen **angemessenen Datenschutz** gewährleistet (Staatenliste des Bundesrats, z.B. alle EU/EWR-Staaten sowie das Swiss-US Data Privacy Framework).

Fehlt ein Angemessenheitsbeschluss (z.B. USA ohne DPF, sonstige Drittstaaten), ist ein Export nur zulässig bei:

- Geeigneten Garantien, insbesondere durch vom EDÖB anerkannte **Standardvertragsklauseln (EU Standard Contractual Clauses mit Schweizer Anpassung)**, oder
- Ausnahmetatbeständen im Einzelfall (ausdrückliche Einwilligung, unmittelbare Vertragserfüllung).

5.4 Betroffenenrechte und Organisatorisches

Definition 5.8. Rechte der betroffenen Personen:

- **Auskunftsrecht (Art. 25 DSG):** Jede Person kann unentgeltlich verlangen, ob und welche Personendaten über sie bearbeitet werden, zu welchem Zweck und an wen sie übermittelt wurden (Frist: in der Regel innert 30 Tagen).
- **Berichtigung und Löschung:** Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten oder Löschung unrechtmässig bearbeiteter Daten.
- **Recht auf Datenherausgabe und -übertragung (Datenportabilität, Art. 28 DSG):** Recht auf Aushändigung der eigenen Daten in einem gängigen elektronischen Format oder Übertragung an einen Drittanbieter.

Definition 5.9. Organisatorische Unternehmenspflichten:

- **Datenschutzerklärung (DSE, Art. 19 DSG):** Umfassende Informationspflicht bei der Beschaffung von Personendaten (Identität, Zweck, Empfänger, Auslandstransfers).
- **Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA, Art. 22 DSG):** Pflicht zur vorgängigen schriftlichen Risikoanalyse bei Bearbeitungen, die ein hohes Risiko für die Persönlichkeit mit sich bringen (z.B. flächendeckende Videoüberwachung, Scoring, KI-Profiling).
- **Privacy by Design & Privacy by Default (Art. 7 DSG):** Systeme müssen

ab Entwicklung datenschutzfreundlich konzipiert sein; Voreinstellungen müssen auf das Minimum an Datenbearbeitung beschränkt sein.

- **Meldepflicht bei Datenschutzverletzungen (Data Breaches, Art. 24 DSG):** Verletzungen der Datensicherheit mit hohem Risiko für die Betroffenen müssen unverzüglich dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) gemeldet werden.

Important 5.10. Strafbestimmungen (Art. 60 ff. DSG): Bei vorsätzlichen Verstössen gegen zentrale DSG-Vorschriften drohen **persönliche Bussen bis zu CHF 250'000.–**:

- Bestraft wird die handelnde **natürliche Person** (z.B. Geschäftsführer, IT-Leiter, Datenschutzbeauftragter), nicht das Unternehmen!
- Strafbar sind u.a.: Falsche oder verweigerte Auskunft (Art. 25 DSG), Verletzung der Informationspflicht (Art. 19 DSG), Missachtung von Sorgfaltspflichten bei der Auftragsbearbeitung oder beim Auslandstransfer sowie Verletzung der beruflichen Schweigepflicht.

5.5 Sonderfälle und Begleitgesetze

Definition 5.11. Spam-Verbot im E-Commerce (Art. 3 Abs. 1 lit. o UWG): Wer Massenwerbung per E-Mail, SMS oder Messenger versendet, handelt unlauter, wenn nicht vorgängig die **Einwilligung der Kunden** eingeholt wurde (**Opt-in-Pflicht**), der korrekte Absender nicht genannt wird oder keine einfache, kostenlose Ablehnungsmöglichkeit vorhanden ist.

Ausnahme (Kundenbeziehung): Keine vorherige Einwilligung nötig, wenn:

1. der Händler die Kontaktadresse beim Verkauf von Waren oder Dienstleistungen erhalten hat,
2. die Werbung ausschliesslich eigene, ähnliche Waren oder Dienstleistungen betrifft, und
3. dem Kunden bereits bei der Erhebung und bei jeder Sendung eine klare Abmeldemöglichkeit geboten wird.

Remark 5.12. Sterneintrag und Telefonwerbung (Art. 3 Abs. 1 lit. u UWG): Unlauter handelt, wer den Vermerk im Telefonbuch („Sterneintrag"), dass ein Kunde keine Werbeanrufe wünscht, missachtet und Werbeanrufe tätigt.

Definition 5.13. EU AI Act (Überblick und Relevanz für die Schweiz): Die Europäische Union reguliert Künstliche Intelligenz nach einem risikobasierten Ansatz:

- **Inakzeptables Risiko:** Vollständig verboten (z.B. Social Scoring, manipulative Verhaltensbeeinflussung, biometrische Echtzeitüberwachung).
- **Hohes Risiko (High-Risk AI):** Strenge Zulassungsvoraussetzungen (Konformitätsbewertung, Risikomanagementsystem, hohe Datenqualität, Transparenz, menschliche Aufsicht; z.B. KI in kritischer Infrastruktur, HR-Bewerberscreening, Kreditwürdigkeitsprüfung).
- **Minimales/Geringes Risiko:** Transparenzpflichten (z.B. Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten / Deepfakes, Offenlegung von Chatbots).

Auswirkung auf Schweizer Unternehmen: Schweizer Firmen unterliegen dem EU AI Act direkt, sobald sie KI-Systeme im EU-Markt in Verkehr bringen oder die Outputs ihrer KI in der EU genutzt werden (Marktortprinzip).

6 Verträge mit IT- und Internet-Providern

6.1 Vertragstypen und rechtliche Qualifikation

Definition 6.1. Klassische gesetzliche Vertragstypen im IT-Recht: Da das Schweizerische Obligationenrecht (OR) keine spezifischen „IT-Verträge“ kennt, werden IT-Leistungen den klassischen Vertragstypen zugeordnet:

- **Werkvertrag (Art. 363 ff. OR):** Geschuldet ist die Herstellung und termingerechte Ablieferung eines **messbaren Erfolgs bzw. Arbeitsergebnisses** (z.B. Programmierung von Individualsoftware, Erstellung einer Website nach Pflichtenheft, Konfiguration, individuelle Anpassungen). Gesetzliche Mängelrechte (Art. 368 OR), formeller Abnahmeprozess und 2 Jahre Gewährleistungsfrist.
- **Auftrag (Art. 394 ff. OR):** Geschuldet ist das **sorgfältige Tätigwerden / Dienstleistung** ohne Erfolgsgarantie (z.B. IT-Consulting, Projektleitung, Support, Schulung, reine Überwachung). Strenge Treue- und Sorgfaltspflicht (Art. 398 OR) sowie **jederzeitiges zwingendes Kündigungsrecht** (Art. 404 OR).

Definition 6.2. Gemischte Verträge und Innominatverträge (Cloud- und SaaS-Modelle): Moderne IT- und Providerverträge vereinen Elemente verschiedener Vertragstypen:

- **SaaS / ASP:** Kombination aus Miete (Softwareüberlassung über das Internet) und Auftrag/Werkvertrag (Betrieb, Datensicherung, Störungsbehebung).
- **IaaS / Hosting:** Miete virtueller Infrastruktur kombiniert mit werkvertraglicher Verfügbarkeit.
- **IT-Wartungsverträge:** Mischung aus Werkvertrag (konkrete Fehlerbehebungen) und Auftrag (Supportbereitschaft, Updates).

6.2 Wesentliche Vertragsinhalte und Service Level Agreements (SLAs)

Definition 6.3. Service Level Agreements (SLAs): SLAs sind standardisierte vertragliche Vereinbarungen zur präzisen Definition, Messung und Durchsetzung der Qualität von IT-Dauerleistungen:

- **Verfügbarkeit (Uptime):** Prozentualer Anteil der vereinbarten Betriebszeit, in dem das System voll funktionsfähig ist (z.B. 99.9% Verfügbarkeit pro Kalenderjahr, bereinigt um geplante, vorab angekündigte Wartungsfenster).
- **Fehlerklassen:** Strukturierung nach Schweregrad:
  - *Kritisch / Blocker:* Gesamtausfall des Systems oder geschäftskritischer Kernfunktionen.
  - *Schwerwiegend:* Erhebliche Beeinträchtigung, jedoch mit Workaround nutzbar.

- *Leicht:* Geringfügige Mängel (z.B. kosmetische UI-Fehler), Kernbetrieb ungestört.

- **Reaktions- und Behebungszeiten:**
  - *Reaktionszeit (Response Time):* Maximale Zeitspanne von der Störungsmeldung bis zum Beginn der aktiven Fehleranalyse durch qualifiziertes Personal.
  - *Wiederherstellungszeit (Recovery Time):* Maximal garantierte Dauer bis zur Behebung oder Bereitstellung eines funktionierenden Workarounds.
- **Sanktionen bei SLA-Verletzung:** Vereinbarung von **Service Credits** (Gutschriften auf nachfolgende Monatsrechnungen) oder Konventionalstrafen (Pönale) sowie ausserordentliche Kündigungsrechte bei wiederholter Nichterreichung der Service-Levels.

Remark 6.4. Mitwirkungspflichten und Leistungsabgrenzung: Ein Provider kann vertragliche Leistungen nur erbringen, wenn der Kunde vereinbarte Mitwirkungspflichten erfüllt (z.B. Bereitstellung von Testdaten, Berechtigungsmanagement, IT-Infrastruktur, rechtzeitige Abnahme). Leistungsstörungen infolge verletzter Kundenmitwirkung entlasten den Provider von seiner Haftung.

6.3 Mängelrechte und Gewährleistung im Werkvertrag

Definition 6.5. Begriff des Werkmangels: Ein Werkmangel liegt vor, wenn das abgelieferte Werk:

- vertraglich ausdrücklich zugesicherte Eigenschaften nicht aufweist (z.B. Nichteinhalten definierter Spezifikationen im Pflichtenheft), oder
- mit Mängeln behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zum vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern (z.B. schwere Software-Crashes oder Datenverlust).

Theorem 6.6. Mängelrechte des Bestellers (Art. 368 OR): Liegt ein Werkmangel vor und wurde dieser rechtzeitig gerügt, hat der Besteller folgende gesetzliche Wahlrechte:

1. **Nachbesserung (Art. 368 Abs. 2 OR):** Kostenlose Beseitigung des Mangels durch den Unternehmer innert angemessener Frist, sofern dies dem Unternehmer keine unverhältnismässigen Kosten verursacht (Hauptanspruch in der IT-Praxis).
2. **Minderung (Art. 368 Abs. 2 OR):** Herabsetzung des Werklohns um den Minderwert, wenn der Mangel nicht behoben werden kann oder eine Nachbesserung fehlgeschlagen ist.
3. **Wandelung (Art. 368 Abs. 1 OR):** Rückgängigmachung des gesamten

Vertrages (Rückzahlung des Werklohns gegen Rückgabe der Software). Nur zulässig bei derart erheblichen Mängeln, dass die Annahme für den Besteller unzumutbar ist.

4. **Schadenersatz (Art. 368 Abs. 1/2 OR):** Kumulativ zu den obigen Rechten kann bei schuldhafter Vertragsverletzung Schadenersatz für Mangelfolgeschäden geltend gemacht werden (Art. 97 OR).

Important 6.7. Prüf- und Rügeobliegenheiten (Verwirkungsfalle, Art. 367 / 370 OR):

- **Prüfpflicht (Art. 367 Abs. 1 OR):** Der Besteller muss das Werk nach der Ablieferung so bald prüfen, wie es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist (z.B. Durchführung von Abnahmetests).
- **Rügepflicht:** Erkannte Mängel müssen dem Unternehmer **sofort** (in der Praxis innert 2 bis maximal 7 Tagen) detailliert angezeigt werden.
- **Versteckte Mängel (Art. 370 Abs. 3 OR):** Mängel, die bei ordnungsgemässer Prüfung nicht erkennbar waren, müssen sofort nach ihrer Entdeckung gerügt werden.
- **Verwirkung:** Versäumt der Besteller die rechtzeitige Rüge, gilt das Werk als **stillschweigend genehmigt**. Sämtliche gesetzlichen Mängelrechte gehen unwiederbringlich verloren!

Remark 6.8. Verjährungsfristen (Art. 371 OR): Mängelansprüche bei beweglichen Werken (einschliesslich Standard- und Individualsoftware) verjähren nach **zwei Jahren** ab Ablieferung des Werks.

6.4 Vertragsbeendigung

Theorem 6.9. Kündigung im Auftragsrecht (Art. 404 OR):

- **Jederzeitiges Kündigungsrecht (Art. 404 Abs. 1 OR):** Ein Auftrag kann von beiden Parteien **jederzeit** fristlos und ohne Angabe von Gründen widerrufen oder gekündigt werden. Dieses Kündigungsrecht ist zwingend und kann vertraglich nicht wegbedungen werden.
- **Kündigung zur Unzeit (Art. 404 Abs. 2 OR):** Erfolgt die Kündigung zur Unzeit (ohne sachlichen Grund in einem ungünstigen Moment, sodass dem Vertragspartner unnötige Nachteile entstehen), ist die kündigende Partei zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens (negatives Interesse) verpflichtet.

Theorem 6.10. Beendigung von Werkverträgen (Art. 377 OR):

- Solange das Werk unvollendet ist, kann der Besteller jederzeit gegen **vollständige Schadloshaltung** des Unternehmers vom Vertrag zurücktreten.
- Der Besteller muss dem Unternehmer die bereits geleistete Arbeit voll vergüten und zusätzlich den entgangenen Gewinn für das gesamte Restprojekt ersetzen.